

- **Procedimiento N°: EXP202401528 (PS/00197/2024)**

RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN N° RR/00796/2024

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad ALL IN DIGITAL MARKETING, S.L., con NIF.: B88369178 (en adelante, la recurrente) contra la resolución dictada por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, el 11/11/24, en el procedimiento EXP202401528 (PS/00197/2024), por vulneración de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante, LSSI) y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11/11/24, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos dictó Resolución en el Procedimiento EXP202401528 (PS/00197/2024), abierto a la entidad ALL IN DIGITAL MARKETING, S.L. con NIF.: B88369178, por la vulneración del artículo 21 de la LSSI, tipificada en el artículo 38.4.d) de la citada norma, con una sanción 5.000 euros (cinco mil euros), por el envío de correos electrónicos de carácter publicitario sin que se hubieran solicitado o expresamente autorizado.

La notificación se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), mediante notificación electrónica el día 13/11/24, según consta en el acuse de recibo incluido en el expediente.

SEGUNDO: Como hechos probados, quedó constancia de los siguientes:

"Primero: Queda constancia en el expediente de la siguiente documentación aportada por el reclamante:

- *Fechado el 14/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamante ***EMAIL.1 a la dirección de correo electrónico, allzoners@allzone.es, conteniendo el siguiente mensaje:*
 - o *"Buenas tardes, he cancelado la inscripción para recibir sus correos electrónicos a través del enlace que aparece en la parte inferior de sus correos unas 10 veces y continúo recibiendo, por lo que solicito que me den de baja inmediatamente de su lista de distribución o procederé a tomar medidas".*
- *Fechado el 19/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamado allzoners@allzone.es, a la dirección de correo electrónico, ***EMAIL.1, con asunto: "ÚLTIMOS DIAS. Participa ahora y llévate GRATIS este pack o viaje a París" y el siguiente mensaje:*
 - o *"SORTEAZO PACK APPLE. - Vótanos..."*

- Fechado el 19/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamante *****EMAIL.1** a la dirección de correo electrónico, allzoners@allzone.es, conteniendo el siguiente mensaje:
 - o “Veo que sigo recibiendo correos electrónicos sin que se haya producido la baja. Esperaré el tiempo que marca la Ley para que se aplique, si pasado ese tiempo sigo recibiendo correos electrónicos por su parte, procederé a interponer la correspondiente denuncia ante la AEPD”.
- Pantallazo de la página de la “Política de Privacidad” de la web <https://allzone.es>, (<https://allzone.es/content/2-politica-de-privacidad>) donde se puede leer, entre otras cuestiones, lo siguiente:
 - o (...) Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de ALL IN DIGITAL MARKETING SL o al correo electrónico habilitado a tal efecto, delegadodatos@allindigital.es, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI por ambas caras o la autorización firmada de su representante legal (...).
- Fechado el 19/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamante *****EMAIL.1** a la dirección de correo electrónico, delegadodatos@allindigital.es conteniendo el siguiente mensaje:
 - o “Mediante el presente correo adjunto documentación para que procedan a darme de baja de la lista de distribución de correos electrónicos publicitarios ya que mediante el enlace de la parte inferior de los correos que recibo y respondiendo a esa misma dirección solicitando la baja no ha resultado efectivo”.
- Fechados el 21/09/23, el 05/10/23, el 12/10/23, el 02/11/23, el 09/11/23, el 14/11/23, el 24/11/23, el 25/11/23, el 14/12/23, 19/12/23 y 23/12/23 copia de los correos electrónicos enviados desde la dirección de correo electrónico, allzoners@allzone.es, a la dirección de correo *****EMAIL.1** conteniendo mensajes publicitarios, como el siguiente:
 - o SORTEAZO. Tus nuevos compañero Apple. Valoramos tiene premio. ¡Últimas horas! Queremos agradecerte tu confianza, para ello no se nos ocurre mejor regalo que ofrecerte la posibilidad de ganar este increíble regalo. Llévate ahora COMPLETAMENTE GRATIS este combo de APPLE (...).

Segundo: Queda constancia en el expediente de la siguiente documentación aportada por la reclamada:

- Pantallazo del formulario “vacío” de registro como cliente en la página web www.allzone.es (inicio → su cuenta) donde se puede comprobar como las

opciones “suscribirse al boletín de noticias” y “he leído y acepto la Política de Privacidad” se encuentran inicialmente desmarcadas.

- Pantallazo de la “Ficha Cliente” del reclamante donde se puede leer, entre otra información, la siguiente:

Estado:	Últimos e-mails enviados:
13/07/2020 Alta	02/02/2024 09:32:45
14/09/2023 Baja	20/09/2023 19:04:37
17/09/2023 Alta	19/09/2023 08:51:23
19/09/2023 Baja	17/09/2023 23:30:44
20/09/2023 Alta	14/09/2023 06:18:55...
02/02/2024 Baja	

- Fechado el 13/07/20 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: HOLA A.A.A., GRACIAS POR SUSCRIBIRSE A NUESTRA NEWSLETTER.
- Fechado el 13/09/23 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: HOLA A.A.A., SE HA DADO DE BAJA CORRECTAMENTE DE NUESTRA NEWSLETTER.
- Fechado el 17/09/20 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: HOLA A.A.A., GRACIAS POR SUSCRIBIRSE A NUESTRA NEWSLETTER.
- Fechado el 19/09/23 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: HOLA A.A.A., SE HA DADO DE BAJA CORRECTAMENTE DE NUESTRA NEWSLETTER.
- Fechado el 20/09/20 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: HOLA A.A.A., GRACIAS POR SUSCRIBIRSE A NUESTRA NEWSLETTER.
- Fechado el 02/02/24 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: HOLA A.A.A., SE HA DADO DE BAJA CORRECTAMENTE DE NUESTRA NEWSLETTER.

TERCERO: Con fecha 12/12/24, tiene entrada en esta Agencia, escrito de recurso de reposición presentado por la recurrente, en el cual manifestaba lo siguiente:

“Primera. – Nos reiteramos en todas y cada una de las alegaciones que hemos venido sosteniendo durante todo el procedimiento. Sucintamente descritas, han consistido en atender la baja solicitada por el reclamante en todas las ocasiones que ha así lo reclamó.

Se ha acreditado, que cuando el reclamante, usuario de nuestros servicios desde el 13/07/2020, pidió ser dado de baja, así fue realizado por All In Digital Marketing S.L., se ha acreditado igualmente, que el reclamante volvió, y ello en diversas ocasiones a ingresar en nuestro sistema, lo que motivó, que dadas las condiciones generales de contratación que aparecen publicadas en nuestra página Web, el reclamante, sabía, y era perfecto conocedor, dando por ende su consentimiento, que tal cuestión originaría nuevas comunicaciones de carácter publicitario, al solicitar darse de baja, nuevamente, así se efectuó nuevamente, y ello en todas las ocasiones que se detallan en la resolución que se recurre.

No se envió comunicación alguna entre los periodos de baja, cumpliendo por lo tanto con el deseo del reclamante, y sólo, cuando volvió a ingresar en la página Web de la aquí recurrente, se repitió el proceso, si se nos permite, tautológico.

Consideramos, por lo tanto, que recibida comunicación el día 19/09/2023 por parte del reclamante de darse de baja en la suscripción a la recepción de correos electrónicos, se le dio de baja en los mismos en la misma fecha, lo que sin duda acredita nuestra disponibilidad a cumplir con el derecho de dicho reclamante, que con las vicisitudes que constan en el expediente, entendemos que esta entidad no es merecedora de la sanción impuesta.

Existe una relación contractual previa, desde el 13/07/2020, que nos permite invocar lo prevenido en el artículo 21.2 de la LSSI.

Segunda. - Entendemos que la sanción impuesta, aplica indebidamente los criterios establecidos en el artículo 40 de la LSSI, dado que a diferencia de lo que establece la resolución que se recurre, el artículo 39.bis de la LSSI, establece: Artículo 39 bis. Moderación de las sanciones. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos: a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el artículo 40. b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente. c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción. d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad. e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.

Artículo 40. Graduación de la cuantía de las sanciones. La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los siguientes criterios: a) La existencia de intencionalidad. b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. c) La reincidencia por comisión de

infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme. d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados. e) Los beneficios obtenidos por la infracción. f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida. g) La adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria aplicable respecto a la infracción cometida, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 18 o en la disposición final octava y que haya sido informado favorablemente por el órgano u órganos competentes. h) La adopción de medidas para mitigar o reparar el daño causado por la infracción. La sanción se limita a citar que “existe intencionalidad”, razonando que tal intencionalidad deviene por cuanto que el reclamante ha intentado darse de baja en el listado de correos publicitarios de esta entidad, tanto a través del enlace existente, como a través del Delegado de Protección de datos de esta entidad, pero sigue recibiendo correos electrónicos. La intencionalidad es, según la norma una circunstancia, entre otras para mitigar la sanción.

La resolución que se recurre ignora el art. 40 de la LSSI para cuantificar la intensidad de la sanción, a saber: a) la intencionalidad (aplicada a sensu contrario), b) no evalúa el plazo de tiempo durante el cual se ha cometido la infracción, c) tampoco la inexistencia de antecedentes es valorada, d) No valora la conducta del afectado, al cual se le dio satisfacción a su reclamación a primer requerimiento, y al ingresar de nuevo en el sistema de la aquí recurrente, provocó que recibiera nuevamente correos electrónicos, e) tampoco valora la resolución la inexistencia de perjuicios, f) ignora que ningún beneficio se ha obtenido por mi mandante, y h) tampoco refiere la resolución que All In Digital S.L., ha tratado en todo momento de dar satisfacción al reclamante mitigando así la infracción.

Por lo expuesto, A LA DIRECTORA DE LA AEPD SOLICITO: Que tenga por interpuesto recurso de reposición frente a la resolución de 11 de noviembre de 2024, y dando lugar al mismo dicte otra que de contrario imperio la deje sin efecto alguno, o subsidiariamente la reduzca al mínimo legal aplicable”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia.

Es competente para resolver el presente recurso la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y el art. 43.1, párrafo segundo, de la LSSI.

II

Contestación a las alegaciones

En relación con las manifestaciones efectuadas en el recurso, cabe señalar lo siguiente:

Primero: Sobre la baja efectiva de los datos del reclamante y la reiteración de su ingreso en el sistema.

Como cuestión previa, procede recordar que en el escrito de reclamación presentado por el reclamante, éste manifestaba que tras haber recibido una multitud de correos electrónicos de naturaleza publicitaria enviados por la entidad, ahora recurrente, solicitó, tanto mediante respuesta a dichos correos como a través de la dirección facilitada en la política de privacidad disponible en su página web, su baja de los sistemas de distribución de correos publicitarios hasta en tres ocasiones. Sin embargo, a pesar de dicha solicitud, continuó recibiendo tales comunicaciones comerciales.

A la reclamación se adjuntaron copias de los correos electrónicos remitidos por el reclamante solicitando su baja de la lista de distribución, así como de los correos publicitarios recibidos con posterioridad a dichas solicitudes.

La entidad sostiene ahora que el reclamante fue dado de baja en todas las ocasiones en que así lo solicitó y que, posteriormente, cuando volvió a ingresar en su sistema, dadas las condiciones generales de contratación que aparecen publicadas en la página Web, el reclamante, sabía, y era perfecto conocedor, *"dando por ende su consentimiento"*, que tal cuestión originaría nuevas comunicaciones publicitarias lo que justificaría la reactivación de los envíos de comunicaciones comerciales.

Sin embargo, tal afirmación no se encuentra debidamente acreditada en el expediente pues se evidencia que, de la documentación aportada por el reclamante junto a su escrito de reclamación, destacan los correos electrónicos enviados los días 14/09/23 y 19/09/23 a la dirección allzoners@allzone.es, en los que manifiesta su deseo expreso de no recibir más correos publicitarios, advirtiendo de la posibilidad de adoptar medidas en caso de persistir el envío de dichas comunicaciones e incluso, el mismo día 19/09/23, el reclamante remitió otro correo electrónico al Delegado de Protección de Datos de la entidad, a la dirección, delegadodatos@allindigital.es, solicitando por tercera vez la baja de la lista de distribución de correos publicitarios.

Por el contrario, de la documentación aportada por la entidad recurrente, en concreto del documento denominado "Ficha Cliente", se desprende que el reclamante figura como dado de "baja" el día 19/09/23 y en estado de "alta" en el sistema el día 20/09/23, tras lo cual recibió hasta 11 correos publicitarios en fechas posteriores, pero no aporta prueba alguna que acredite que el reclamante otorgase su consentimiento expreso para recibir nuevamente publicidad comercial después de haber dejado hasta tres veces su deseo de no volver a recibir más comunicaciones comerciales. Esto es, no se aporta ninguna evidencia que pueda demostrar que el reclamante volviese a dar su consentimiento expreso para volver a recibir comunicaciones comerciales.

Pues bien, en este sentido, el artículo 21 de la LSSI indica que queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por el destinatario y en el caso que nos ocupa, la revocación del consentimiento por parte del reclamante fue clara, reiterada y documentada, sin que la recurrente cesara en el envío de comunicaciones comerciales, por lo que, en este caso no pueden ser tenidas en cuentas las alegaciones presentadas en este punto.

Segundo: Sobre la aplicación del artículo 40 de la LSSI.

Como cuestión previa, procede recordar que, en la resolución del expediente sancionador, (PS/00197/2024), se consideró graduar la sanción a imponer de acuerdo con el criterio agravante que se establece el art. 40.a) de la LSSI: *“La existencia de intencionalidad (apartado a), pues se constata que el reclamante ha intentado darse de baja en el listado de correos electrónicos publicitarios de la entidad reclamada en varias ocasiones, tanto a través del enlace existente en los correos recibidos como a través del Delegado de Protección de datos de la entidad, pero sigue recibiendo correos electrónicos publicitarios”*.

La reclamada argumenta que la sanción impuesta no ha valorado correctamente los criterios de graduación del artículo 40 de la LSSI, alegando, entre otros, que no existe intencionalidad, que no se han obtenido beneficios y que la conducta del afectado ha influido en la infracción. No obstante, estas alegaciones no pueden ser tenidas en cuenta por los siguientes motivos:

En primer lugar, la recurrente persistió en el envío de correos electrónicos comerciales a pesar de recibir hasta tres solicitudes claras e inequívocas del deseo de darse de baja del reclamante, lo que demuestra una actuación negligente cuando menos, si no deliberada.

Según el artículo 40.b de la LSSI, la duración de la infracción es un criterio a considerar en la graduación de la sanción. Pues bien, recordemos que el reclamante solicitó la baja el 14/09/23, reiterándola el 19/09/23, sin que ello produjera efecto, continuando la recepción de comunicaciones comerciales hasta el 23/12/23. Se trata de un periodo de más de tres meses, lo que evidencia una persistencia en la conducta infractora pero debemos recordar que esto en la resolución no fue considerado como agravante pero lo que tampoco se le puede considerar es como atenuante

La entidad recurrente sostiene que no cuenta con antecedentes sancionadores, lo que debería considerarse como un factor atenuante. Sin embargo, la ausencia de reincidencia no exime de responsabilidad ni justifica la reducción de la sanción. De hecho, el artículo 40.c de la LSSI establece que la reincidencia es un agravante, pero no contempla la falta de antecedentes como atenuante.

La entidad recurrente sostiene que no se han causado perjuicios al reclamante, sin embargo, el artículo 40.d de la LSSI no limita los perjuicios a daños económicos, sino que comprende cualquier afectación derivada del incumplimiento de la normativa. La existencia de perjuicio no requiere que el reclamante acredite un daño concreto, sino que se valore la afectación a sus derechos fundamentales.

La entidad recurrente afirma que no ha obtenido beneficios con el envío de correos electrónicos publicitarios, sin embargo, la propia persistencia en la remisión de publicidad indica una finalidad comercial que persigue generar un beneficio potencial. Así, valorar la ausencia de beneficios como una atenuante anularía el efecto disuasorio de la multa, en la medida en que minora el efecto de las circunstancias que inciden efectivamente en su cuantificación, reportando al responsable un beneficio al que no se ha hecho merecedor. Sería una rebaja artificial de la sanción que puede llevar a entender que infringir la norma sin obtener beneficios, financieros o del tipo

que fuere, no le producirá un efecto negativo proporcional a la gravedad del hecho infractor.

La entidad recurrente menciona que ha tratado de dar satisfacción al reclamante y corregir la situación, no obstante, la falta de una respuesta diligente en la gestión de la baja definitiva del reclamante demuestra que la empresa no adoptó medidas efectivas en tiempo y forma para mitigar la infracción.

Por último, la entidad recurrente pretende acogerse a la moderación de las sanciones prevista en el artículo 39 bis de la LSSI, pero esta no resulta aplicable en este caso, ya que ninguna de las circunstancias previstas en dicho artículo concurren de forma significativa pues no existe una cualificada disminución de la culpabilidad o de la antijuridicidad de la conducta, ya que la infracción es evidente al enviar comunicaciones comerciales después de haber solicitado hasta en tres ocasiones su deseo de no volver a recibirlas. No se ha producido una regularización diligente de la situación irregular, pues el reclamante tuvo que insistir reiteradamente en su solicitud de baja sin obtener una respuesta eficaz. No se ha acreditado que la conducta del afectado haya inducido a la comisión de la infracción, ya que la empresa no ha probado que el usuario otorgara un nuevo consentimiento tras solicitar la baja y por último, el infractor no ha reconocido espontáneamente su culpabilidad, sino que, por el contrario, ha intentado trasladar la responsabilidad al reclamante.

III

Resolución extemporánea

Debido a razones de funcionamiento del órgano administrativo, por ende, no atribuibles a la parte recurrente, hasta el día de la fecha no se ha emitido el preceptivo pronunciamiento de esta Agencia respecto al presente recurso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 LPACAP, el sentido del silencio administrativo en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones es desestimatorio. Con todo, y a pesar del tiempo transcurrido, la AEPD está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, según dispone el artículo 21.1 de la citada Ley.

En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio, según dispone el artículo 24.3 de la misma ley. Por tanto, procede emitir la resolución que finalice el procedimiento del recurso de reposición interpuesto.

III

Conclusión

En consecuencia, en el presente recurso de reposición, la parte recurrente no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada por lo que, vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos **RESUELVE:**

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la entidad ALL IN DIGITAL MARKETING, S.L. con NIF.: B88369178 contra la resolución dictada por la

Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, el 11/11/24, en el procedimiento EXP202401528 (PS/00197/2024).

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad ALL IN DIGITAL MARKETING, S.L.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la DA cuarta del referido texto legal.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada LPACAP. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

Lorenzo Cotino Hueso,

Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos